

1501673-55.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... são condutas comuns aos delitos de tráfico ilícito e uso indevido, do que resulta, pelo princípio da exclusão, quando não se tratar de uso indevido, reconhecer o narcotráfico. Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Tatuí-SP - cep 18278-440

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501673-55.2021.8.26.0571

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2347639/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22082234 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 3041/21/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2347639 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLYNTON WESLEY GABRIEL NOGUEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

1º Juiz(a) de Direito Auxiliar: Dr(a). FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA

Vistos.

WELLYNTON WESLEY GABRIEL NOGUEIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso na figura típica descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 com incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porquanto, segundo narra a denúncia, no dia 21 de dezembro de 2021, por volta das 17h30, na Rua Florindo Antunes Machado, nº 580, nesta Cidade e Comarca de Tatuí, transportava e tinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 09 (nove) porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1,95 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,

além de 01 (um) aparelho de telefone celular e da importância de R\$ 1.495,00 (mil quatrocentos e noventa e cinco reais) em dinheiro.

O réu foi notificado (fl. 88) e ofertou sua defesa prévia (fls. 96/97).

A denúncia foi recebida no dia 21 de fevereiro de 2022 (fls. 98/100) e o acusado foi citado (fl. 111).

Durante audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas e, ao final, o réu foi interrogado. A instrução foi encerrada e as partes apresentaram suas alegações finais em forma de debates orais (fls. 113/118).

Os autos vieram para a conclusão.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada que tramita em desfavor de WELLYNTON WESLEY GABRIEL NOGUEIRA, o qual, segundo consta da peça inicial acusatória, transgrediu o preceito primário da norma penal incriminadora inserida no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 com incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Cotejadas as provas colhidas nesta ação penal, verifica-se que os fatos descritos na denúncia foram cabalmente demonstrados, de modo que se impõe o acolhimento da pretensão punitiva.

Deveras, sabe-se que é necessário, para toda e qualquer condenação, que exista juízo exauriente acerca da autoria e materialidade delitiva.

A materialidade do delito está comprovada através do boletim de ocorrência de fls. 09/11, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 14, laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 79/82, comprovante de depósito judicial de fl. 85 e pela prova oral colhida.

De igual modo, a autoria é inconteste.

Feitas as considerações iniciais, passo à análise da prova oral, notadamente aquela colhida em audiência.

Durante a instrução, o policial militar OTNIEL ARRUDA BARTA DA SILVA disse que na data dos fatos sua equipe realizava patrulhamento pelas ruas do Bairro Vila Esperança, local conhecido pelo intenso comércio de drogas. Em dado momento, avistaram o acusado enquanto saía do interior de um veículo da marca Volkswagen e modelo Gol. Ao notar a presença da viatura policial, o réu ficou nervoso, razão pela qual foi efetuada a sua abordagem. Destacou que Wellynton Wesley é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Em poder do acusado foram encontradas a quantia de dez reais e trinta e cinco centavos, bem como um aparelho celular. No interior do veículo, notadamente em sua porta traseira do lado esquerdo, foi apreendido um pacote com nove porções de cocaína. Ainda, foi localizada uma carteira contendo o documento de identificação pessoal do acusado, além da quantia de mil quatrocentos e oitenta e cinco reais escondida no console do câmbio do automóvel. Indagado, Wellynton Wesley confirmou à equipe a distribuição de drogas no local e apontou que vendia cada porção de cocaína por dez reais. Sobre o automóvel, o réu mencionou que era de sua propriedade. Em seguida, o acusado foi conduzido ao Pronto Socorro e à Delegacia de Polícia. Por fim, indagado pela Defesa, o depoente disse que apenas avistou o acusado sair do automóvel antes de ser abordado.

A testemunha VANDERSON ESTEVAM BARBOSA, policial militar, ratificou o depoimento ofertado por seu colega de farda Otaniel Arruda Barta da Silva. Destacou que o réu informou à equipe policial que praticava o comércio ilícito e que já havia vendido uma porção de cocaína para um usuário pelo valor de dez reais.

Por sua vez, perante a Autoridade Policial, o réu WELLYNTON WESLEY GABRIEL NOGUEIRA disse que na data dos fatos estava com o veículo parado quebrado em via pública. Aguardava o mecânico quando foi abordado pelos policiais militares. Informou que a droga encontrada dentro do automóvel não lhe pertencia. O carro era de seu padraço e ele não faz uso de drogas. Disse ser usuário de maconha e cocaína (termo de interrogatório de fl. 05). Em seu interrogatório judicial, colhido sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa, contou já ter sido processado pela prática do delito de tráfico de drogas, bem como possui cinco passagens pela Vara da Infância

e Juventude pela prática do ato infracional análogo ao mesmo crime e, em todas elas, foi atribuída para ele medida socioeducativa de internação. Nunca trabalhou com registro em CTPS. Apenas auxiliava seu padrasto. Não terminou seus estudos. Quanto aos fatos, negou a prática do crime a ele atribuído na denúncia. Disse não saber o que o policial Barta tem contra sua pessoa, pois não está envolvido com o tráfico de drogas. Apesar de seus envolvimento com o comércio espúrio na infância, mudou de vida e não mais comete atos ilícitos. Salientou que estava no local aguardando a chegada de um mecânico. Apenas estava com a quantia de trezentos reais deixada por seu padrasto para pagar o serviço de mecânica. Não sabe a origem do restante do dinheiro e das drogas apontadas pelos policiais militares.

Os depoimentos e o interrogatório foram captados por meio de sistema audiovisual, nos termos do Provimento CGJ 08/2011 e das Leis nº 11.419/06 e 11.719/08, e através de videoconferência, mediante utilização do aplicativo Teams/Microsoft, com a disponibilização da mídia em pasta digital, em decorrência da pandemia do Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020.

Pois bem. Diante do conjunto de provas amealhado aos autos, outra conclusão não é possível, senão a procedência da ação penal.

Finalizada a instrução, temos que o conjunto probatório leva à conclusão de que o réu é responsável pela prática do delito; a assertiva é lógica e harmoniza-se com os elementos colhidos no decorrer do feito. As porções de drogas encontradas, as circunstâncias da prisão em flagrante e as declarações dos agentes de segurança evidenciam a finalidade de tráfico.

A prova oral colhida, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, formam um conjunto apto à formação de um juízo de convencimento quanto ao tráfico exercido pelo réu.

Vale citar: "Adquirir, guardar ou trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, substância entorpecente, são condutas comuns aos delitos de tráfico ilícito e uso indevido, do que resulta, pelo princípio da exclusão, quando não se tratar de uso indevido, reconhecer o narcotráfico. Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - AC 1.185/93 - Rel. Enéas Machado Cotta - TDTJRJ 23/288).

Vale dizer que a lei pune o tráfico ilícito de entorpecente em qualquer de suas condutas, típicas e exclusivas. Em tema de entorpecente, as condutas de "transportar" e "ter em depósito" sem autorização legal ou regulamentar, a droga proibida, basta para integrar a figura criminosa do tráfico ilícito.

Também é importante mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do acusado, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada.

Nesse sentido: "... nenhum impedimento legal existe ao testemunho de investigadores e pessoas ligadas à polícia. Seus depoimentos devem ser considerados, examinados e pesados em cada caso, como o de outra testemunha qualquer. Nunca, porém, sumariamente afastados como de todo imprestáveis. Desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória." (Ap.Crim. 103.701 TJSP);

"... a simples condição de policial não torna a testemunha suspeita ou impedida" (STF - RT 68/64);

"... não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contrassenso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito." (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221).

Portanto, o quadro probatório é eficaz e conclusivo em relação à materialidade e autoria dos fatos narrados.

Ressalto que ficou suficientemente delineado nos autos que a equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo Bairro Vila Esperança e, ao passarem pelo local dos fatos, avistaram o acusado que, ao notar a aproximação da viatura, inexplicavelmente apresentou excessivo nervosismo.

Diante da atitude suspeita, o acusado foi abordado e revistado pelos agentes públicos, ocasião em que com ele foi encontrada a quantia de dez reais e trinta e cinco centavos e um aparelho celular.

Em buscas no automóvel, em sua porta traseira do lado esquerdo foram localizadas nove porções de cocaína e, escondida no console do câmbio do automóvel foi encontrada uma carteira com o documento de identificação pessoal do acusado e a quantia de mil quatrocentos e oitenta e cinco reais.

Indagado, o réu confessou a mercancia ilícita aos agentes responsáveis por sua prisão, destacando que vendia cada porção de droga por dez reais e que já havia fornecido uma delas para um usuário e, tendo em vista a constatação do ilícito, foi conduzido à Delegacia de Polícia para lavratura do auto de prisão em flagrante. Convém lembrar não ser preciso para a caracterização da narcotraficância que o agente seja surpreendido no exato momento em que fornece materialmente a droga a terceira pessoa, bastando circunstâncias seguras de que para tanto se destina o tóxico encontrado, e este é o caso dos autos.

A negativa do réu está em desacordo com todo o contexto probatório e, portanto, distante da realidade fática, não se prestando a influir no convencimento deste magistrado. Inexistentes nos autos quaisquer elementos tendentes a roborar sua versão.

Não é crível a alegação do acusado referente à intenção dos policiais militares, notadamente o servidor Otniel Arruda Barta da Silva, em imputar para ele uma acusação falsa relacionada a crime de grave natureza.

Embora argumente que já teria sido abordado e preso em outra ocasião pelo mesmo agente público, tal fato não induz à conclusão de que o policial militar atue tão somente na intenção de incriminar o réu de forma injusta, valendo-se, inclusive, de porções de drogas e quantia considerável de dinheiro para concretizar seu alegado intento.

Além do mais, nada concreto o réu indicou a fim de justificar que foi injustamente apontado como o responsável pela venda das drogas no local.

Ora, como já apontado, os depoimentos dos policiais militares estão em consonância com todos os elementos de prova coligidos, não sendo o caso de desprestigiá-los, na medida em que coesos e dotados de verossimilhança.

Cabe pontuar que a abordagem do réu se deu em local próximo ao qual ele já havia sido preso em flagrante com outro indivíduo e um adolescente, fatos estes que são apurados nos autos do Processo nº 1501241-36.2021.8.26.0571 em trâmite por esta 1ª Vara Criminal e que foram distribuídos a este Juízo Auxiliar para a realização da instrução e prolação de sentença emitida em data recente, ou seja, em 11.03.2022. Diferentemente do quanto sustentou a Defesa, não há nos relatos dos agentes públicos quaisquer contradições ou equívocos, pois ambos narraram com detalhes a constatação da prática ilícita levada a efeito pelo réu.

No mais, a Defesa não logrou trazer aos autos nenhum elemento que fosse capaz de, ao menos, colocar em dúvida algum ponto do acervo probatório constituído nestes autos, o qual se revela farto e demonstra com riqueza de detalhes toda a ação delituosa.

Inconteste, pois, a ocorrência de todos os elementos típicos, subjetivos e objetivos, necessários para a responsabilização do réu pela prática do delito disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase do critério trifásico, atento aos critérios estipulados no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, inexistente circunstância judicial negativa a influir em desfavor do acusado.

A informação constante na certidão acostada aos autos (fls. 21/22) quanto à existência de outro processo em andamento em desfavor do acusado não se presta a influir nesta etapa da dosimetria da pena.

Isso porque, como é cediço, inquéritos policiais e ações penais em curso ou com

sentença homologatória de transação penal ou, ainda, com sentença extintiva da punibilidade não tornam referidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em atenção à Súmula nº 444 do STJ e artigo 76, §§ 4º e 6º da Lei nº 9.099/95. No mais, a quantidade de drogas não destoa daquela comumente constatada em situações de narcotraficância. Desta forma, fixo a pena-base no mínimo legal, a saber: 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, assim como já declinado nos autos do Processo nº 1501160-87.2021.8.26.0571, ressalvado o entendimento até então adotado por este Juízo em relação à circunstância agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (crime praticado em período de calamidade pública), passo a adequar-me à orientação recorrente provinda das Cortes Superiores no tocante à natureza subjetiva da referida agravante, razão pela qual afasto sua incidência ao caso em comento.

Neste sentido, confira-se:

"Em relação à agravante prevista no art. 61, I, "j", do Código Penal, verifica-se que a sanção do paciente foi novamente exasperada em 1/6, porque os fatos foram cometidos durante a pandemia do coronavírus, estado esse de calamidade pública; Todavia, entendo que deve ser afastada a referida agravante, pois sua incidência pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitativa." (STJ - AgRg no HC 677.124/SP; 5ª Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julgamento: 03.08.2021).

"Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexó com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico." (STJ - AgRg no HC 669.508/SP; 6ª Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julgamento: 15.06.2021).

De igual modo, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Veja-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena redimensionada - Afastamento da agravante da calamidade pública - Ausência de nexó causal - Regime prisional fechado mantido - Recurso parcialmente provido." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1501003-51.2020.8.26.0571; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal;

Relator(a): Desembargador(a) Jucimara Esther de Lima Bueno; Origem: Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Julgamento e Publicação: 15.02.2022).

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE 47,1 GRAMAS DE COCAÍNA E 21,5 GRAMAS DE MACONHA - MERCANCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO CORRETA, POIS LASTREADA EM PROVA FIRME DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PENAS - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA "j" (calamidade pública) - NECESSIDADE. Não há prova de que o réu se valeu da pandemia causada pelo COVID-19 para praticar o delito - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1501141-18.2020.8.26.0571; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Willian Campos; Origem: Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Julgamento e Publicação: 01.09.2021).

O réu faz jus à circunstância atenuante disposta no artigo 65, inciso I, do Código Penal, eis que na data do fato era menor de vinte e um anos. No entanto, deixo de considerá-la, pois a pena nesta etapa não pode ficar aquém do mínimo legal, em atenção ao teor da Súmula nº 231 do STJ.

Desta feita, mantenho a pena intermediária no patamar fixado na etapa inicial.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º. Embora primário, o réu possui processo em andamento pela sua incursão na prática recente de delito de igual natureza ao que se julga, cujo fato se deu em 15.09.2021, no qual já foi proferida sentença condenatória por este Juízo em 11.03.2022 e aguarda o trânsito em julgado ou a interposição de recurso à Superior Instância (certidão de objeto e

pé de fls. 21/22 - Processo nº 1501241-36.2021.8.26.0571).

Pontuo, ainda, que nos autos do Processo nº 1501241-36.2021.8.26.0571 o réu foi agraciado com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares e, aproveitando-se do benefício a ele concedido, retornou à mercancia espúria. Tal quadro desponta para a dedicação do agente à atividade criminosa, cujo posicionamento encontra amparo no entendimento adotado pelo C. STJ, segundo o qual "a existência de processos em andamento são aptos a demonstrar que o agente se dedica a atividades criminosas, obstando a aplicação do redutor já mencionado" (STJ - REsp 1575321 SC 2015/0321747-3; Relator: Ministro NEFI CORDEIRO; DJ 20.06.2017). De se destacar que a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de drogas, em relação a quem responde a ações penais ou figura como investigado em inquéritos policiais viola sobremaneira o princípio da isonomia, pois o acusado será tratado da mesma forma que alguém sem qualquer registro ou passagem na Justiça Criminal.

Acerca do tema, confira-se:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito". Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça." (STJ - EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017) - destaquei.

Ainda: "processos em andamento só não podem ser utilizados na primeira fase de dosimetria da pena para majorá-la, sendo possível utilizar esses fatos criminais para justificar o afastamento da redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como na hipótese dos autos" (HC 390.530/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Destarte, sendo certo que a referida causa especial de diminuição de pena somente deve ser concedida em prol daqueles que, a despeito de condenados pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, estão se iniciando no mundo do crime, tendo, por isso, maior chance de serem recuperados e reintegrados ao convívio social, mediante a imposição de sanções penais menos rigorosas. Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4º, do artigo 33, da lei em comento, o que não se verifica no caso dos autos.

Além do mais, conforme se observa da certidão de fls. 23/24 e até mesmo do interrogatório do acusado colhido em audiência, Wellynton Wesley dedica-se ao comércio ilícito desde a menoridade, ostentando cinco passagens pela Vara da Infância e Juventude pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, todas elas com aplicação de medida socioeducativa de internação.

Como se sabe, o registro de ato infracional não se presta a gerar maus antecedentes ou reincidência, mas é motivo apto para afastar a incidência do tráfico privilegiado, denotando que o réu ostenta conduta permeada pela prática de atos

antissociais.

Neste viés, inclusive, "... conquanto o ato infracional (...) não possa ser considerado para fins de reincidência, ou mesmo como maus antecedentes, serve perfeitamente para demonstrar sua periculosidade, bem assim sua propensão ao cometimento de delitos da mesma natureza (...)" (HC 33614/DF; 5ª Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; j. 2-6.2005; DJ 20-6-2005; p. 302).

Ainda:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DO ENTORPECENTE. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE PARCIALMENTE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n.11.343/2006). 3. Concluído pela instância antecedente, diante de anterior registro de ato infracional análogo ao delito de tráfico de entorpecentes, que o paciente se dedica a atividade criminosa, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. (...)" (HC 435.685/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018) - destaquei. Anoto, por fim, que o réu sequer comprovou ter ocupação lícita à época dos fatos, pois desempregado e nunca exerceu qualquer atividade lícita (conforme se observa dos documentos de fls. 06 e 07 atinentes à sua qualificação e às informações sobre a vida pregressa, bem como de seu interrogatório judicial), não logrando apontar a origem lícita do valor expressivo de dinheiro com ele apreendido, qual seja a quantia de R\$ 1.495,35 (mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), o que dá a necessária certeza de que os entorpecentes se destinam ao tráfico ilícito, deixando patente que ele se dedicava às atividades criminosas. Portanto, a reprimenda fica estabelecida de forma definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E BENESSES LEGAIS.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por restarem não atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal; o regime de cumprimento fixado para o tráfico de entorpecentes e a própria natureza do delito, que é móvel de grande parte de outros crimes cometidos para a manutenção do vício, impedem a concessão da benesse por restar desatendido o inciso III do dispositivo legal retro mencionado.

Pelas mesmas razões, resta desatendido o inciso II do art. 77 do Código Penal, inviabilizando a suspensão condicional da pena.

Fixo, como regime inicial de cumprimento de pena para o delito de tráfico de drogas, observadas as colocações feitas por ocasião da não substituição da pena privativa, o REGIME FECHADO, único que se mostra compatível com a gravidade do delito e sua potencialidade lesiva.

Ainda quanto a fixação do regime inicial fechado, colhem-se os seguintes julgados proferidos pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO

INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A

HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. "Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado". RECURSO NÃO PROVIDO." (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva; Data do julgamento: 27/06/2013) - sem destaques no original;

"No concernente ao regime prisional impositivo à espécie, também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei nº 11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e, a duas, porque o crime de tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além da desagregação da instituição familiar" (TJSP AP. nº 990.09.042255-6 Rel: Des. Paulo Rossi) - sem destaques no original;

"Tráfico de drogas Recurso defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e a fixação do regime prisional aberto - Provas francamente incriminadoras - Condição de usuário que não elide a concomitante atividade de traficância - Crime de perigo abstrato, não se exigindo que o infrator seja flagrado no próprio ato de venda da mercadoria proibida. Pena que não comporta reparo. Réu beneficiado com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Regime prisional fixado com critério - Crime equiparado a hediondo, ensejando a aplicação, inicialmente, de um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito - Personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública, de quem envereda para a prática desse tipo de criminalidade - Inaplicabilidade do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal - A competência para se discutir a respeito da detração penal é do juízo das execuções - Negado provimento." (TJSP. AP nº 0001719-19.2014.8.26.0263, Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Fernando Simão. Data do Julgamento: 10/09/2015) - sem destaques no original.;

"Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a iminência da abordagem por guardas municipais, desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de maconha, 19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização, em seu poder e ao ensejo de revista, de R\$ 62,00 sem comprovação satisfatória de origem. Palavras dos guardas municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias dissonantes e das mais inconsistentes. Alegação de flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da conduta repellido. Condenação, pelo tráfico, bem decretada. Penas que já beneficiam o acusado. Redução, com lastro no artigo 33, § 4º, não questionada pela acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos incompatível com crime equiparado a hediondo. Regime fechado necessário e decorrente, inclusive, de lei (Lei nº 11.464/07). Apelo improvido." (TJ/SP. AP 0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Pinheiro Franco. Data do julgamento: 04/07/2013) - sem destaques no original.

E, ainda, o quanto já decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando familiares". (In RTJ 123/547).

Soma-se a tal que é de entendimento deste juízo, em casos como este, quanto a dever ser rigorosa a repressão ao delito em tela, não havendo que se descurar, inclusive, que os supramencionados dispositivos constitucionais e legais, encontram pleno amparo na Convenção de Viena, de 1991, de Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no país pelo Decreto nº 154/91, especialmente aos seus artigos 4º, "a", 6º e 7º. Atento a tais características do delito praticado, a quantidade de pena e regime impostos, reputo necessária a manutenção custódia cautelar para a garantia da ordem

pública e para assegurar a aplicação da lei penal, motivo pelo qual, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

No sentido exposto, o magistério de Júlio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis:

“O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”.

E, ainda, no seguinte julgado, in verbis:

“Há lesão à ordem pública quando os fatos noticiados nos autos são de extrema gravidade, causando insegurança jurídica a manutenção da liberdade do acusado”. (STF, HC nº 90.726, Rel. Min. Carmem Lúcia, v.u.).

Ausentes nos autos informações acerca da situação econômica do réu, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu WELLYNTON WESLEY GABRIEL NOGUEIRA, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 combinado com o artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Conforme fundamentado acima, NEGADO O APELO EM LIBERDADE. RECOMENDE-SE O RÉU JUNTO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA RECOLHIDO.

Com relação à detração penal como parâmetro para estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, mercê do que dispõe o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, urge proceder-se a uma interpretação sistemática da norma, atentando-se que o estabelecimento do regime inicial é pautado também pelas circunstâncias do delito (artigo 33, do Código Penal). Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão e acompanhamento do cumprimento da pena aplicada na fase da Execução.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, caso tal medida ainda não tenha sido providenciada.

DECLARO o perdimento do numerário e dos bens apreendidos com o réu, quais sejam a quantia de R\$ 1.495,35, o aparelho celular da marca Samsung de cor dourada e o veículo VW/Gol 16V, de placa CPE1C22 de Tatuí, ano de fabricação e modelo 1998, de cor cinza, combustível álcool e gasolina, chassi 9BWZZZ373WT020402 (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e comprovante de depósito judicial de fl. 85), em favor da União, para ser revertido diretamente ao Funad, nos termos do artigo 91, inciso II, alíneas “a” e “b”, do Código Penal c.c. o artigo 63 e parágrafos, da Lei nº 11.343/06.

O réu está assistido por Defensora nomeada, circunstância que gera a presunção de não dispor de recursos para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Assim, incabível se mostra a condenação ao pagamento das custas, de modo que concedo em seu favor os benefícios da Gratuidade da Justiça.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários à Advogada que atuou no feito patrocinando os interesses do réu (fl. 89), nos termos do Convênio DPE/OAB.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente e demais comunicações necessárias.

P.I.C.
Tatui, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA